

1010805-31.2022.8.26.0161

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Luiz Fernando Parreira Milena

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5.

Recurso especial provido. (STJ, 3ª Turma, REsp 1.058.221-PR, Reg. 2008/0104709-0, J. 04.10.2011, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU 14.10.2011).

Nessa especial circunstância, à míngua de comprovação na regularidade do débito, que ensejasse os descontos, no importe de R\$ 197,17, debitados mensalmente no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara do Juizado Especial Cível - Comarca de Diadema

Av. Sete de Setembro, 359, Diadema, SP, CEP 09912-010

email: diademajec@tjsp.jus.br - fone: 4056-6600

SENTENÇA

Processo nº:

1010805-31.2022.8.26.0161

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

José dos Santos

Requerido:

Banco Mercantil do Brasil S/A

Juiz de Direito: Dr. Luiz Fernando Parreira Milena

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95.

DECIDO.

Inicialmente, considerando que as partes não manifestaram interesse na produção de provas orais, fica dispensada a realização da audiência de instrução e julgamento. No mais, tendo em vista que o negócio jurídico havido entre as partes compreende obrigação de trato sucessivo, ainda não integralmente adimplida, não há que se falar em prescrição, na medida em que a contagem do respectivo prazo somente terá início com o vencimento da última parcela do contrato. Neste sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

APELAÇÃO. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada. Realização de diversas diligências para localização do apelante, sem êxito. Citação por edital válida. Contrato devidamente assinado pelo apelante. Nulidade afastada. O termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, por se tratar de contrato de trato sucessivo. Prazo quinquenal, art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível n. 0000241-02.2008.8.26.0484)

REVISÃO DE CONTRATO - PRESCRIÇÃO - Pretensão de reforma da decisão que entendeu que o contrato, cuja revisão se pretende, não poderia ser revisado no que tange ao período anterior a dez anos da data da propositura da demanda, por força da prescrição - Cabimento - Hipótese em que o contrato bancário discutido entre as partes é de trato sucessivo e só pode ser alcançado pela prescrição após o seu

encerramento. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 0537126-81.2010.8.26.0000)

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. 1) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês. 2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. Recurso parcialmente provido. (TJSP;

Apelação Cível 1002099-81.2020.8.26.0047)

DECADÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inocorrência - Contrato de trato sucessivo, com descontos mensais em benefício previdenciário da autora - Inaplicabilidade do art. 178 do CC/2002 - Sentença reformada neste tópico. CONTRATO - Contrato de mútuo com emissão simultânea de cartão de crédito consignado e reserva de margem consignada no benefício previdenciário da autora (RMC) - Validade do contrato - Autora não nega a contratação do mútuo (empréstimo consignado), mas questiona a contratação de cartão de crédito consignado - Vício de consentimento - Inocorrência - Existência de elementos nos autos que comprovam a contratação do cartão com pagamento do valor mínimo da fatura mensal mediante desconto direto no benefício previdenciário da autora - Prevalência da forma contratada pelas partes e obediência ao "pacta sunt servanda" - Descontos de operações de cartão de crédito nos proventos de aposentadoria são admissíveis - Improcedência da ação declaratória c. c. repetição dobrada do indébito e indenização por dano moral mantida - Recurso acolhido apenas para afastar a decadência - Ação julgada improcedente. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1007711-17.2020.8.26.0009).

Por outro lado, considerando que a pretensão da parte autora não foi satisfeita pelo consenso, tem ela necessidade de obtê-la pela via jurisdicional, o que configura, justamente, o interesse de agir.

No mérito, segundo se depreende dos termos da petição inicial e os respectivos documentos que a instruíram, o autor impugna o contrato bancário de número 002394527, datado de 01.05.2017, celebrado com o Banco-réu, bem como os respectivos descontos mensais efetivados em seu benefício previdenciário, no importe mensal de R\$ 197,17, indicados no "demonstrativo de empréstimos bancários" juntado a folhas 18, sob o argumento de que nunca celebrou o referido contrato.

Por tais razões, o autor pretende a declaração de nulidade do mencionado negócio jurídico, bem como a condenação do réu na obrigação de fazer consistente em cessar os respectivos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, bem como que este se abstenha de incluir o seu nome e CPF nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, além de restituir-lhe, em dobro, as respectivas quantias já descontadas e, finalmente, pagar uma indenização, a título de danos morais.

Em contestação, o Banco-réu argumenta que a operação bancária impugnada diz respeito a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, regularmente contratado pelo autor.

Sendo de consumo a relação jurídica havida entre as partes e verossímeis os fatos aduzidos na inicial, mormente diante dos documentos anexados aos autos, aplicável à hipótese dos autos o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do

Consumidor, relativamente à inversão do onus probandi.

Sob este prisma, o pedido inicial é procedente, ainda que parcialmente, na medida em que a instituição financeira-ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das mencionadas operações bancárias, na forma como dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o Banco-réu não demonstrou que os serviços bancários prestados ao autor não eram defeituosos, na acepção jurídica que lhe empresta o Código de Defesa do Consumidor.

Em outras palavras, o réu não comprovou, satisfatoriamente, a segurança de seus serviços, ou seja, que inexistia qualquer defeito, sendo impossível, ou pouco provável, a sua utilização por terceiros não autorizados, em detrimento dos interesses do autor.

Com efeito, ainda que, aparentemente, demonstrada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado por parte do autor, como se depreende dos documentos juntados a folhas 100/111, o Banco-réu não comprovou a emissão e a entrega do referido cartão ao autor, muito menos a origem das operações bancárias a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário deste, a partir de 01.05.2017, no importe mensal de R\$ 197,17.

De fato, a instituição financeira-ré não apresentou qualquer documento que comprovasse que o autor tenha utilizado o mencionado cartão de crédito para a realização de compras ou mesmo que este tenha se utilizado do crédito disponível no respectivo cartão para a realização de saques e transferências bancárias, inexistindo, sequer, qualquer prova acerca da emissão e entrega do mencionado cartão ao autor.

Por outro lado, como sabido, a administradoras de cartões de crédito, na qual se enquadra a instituição bancária ré, ao contratar com os estabelecimentos comerciais que utilizam o referido sistema de pagamento, exige destes a análise formal dos cartões de créditos que lhe são apresentados por seus clientes, mediante a conferência das assinaturas e apresentação de documento de identidade. Se os estabelecimentos credenciados descumprem tal obrigação de cuidado e vigilância, gerando falhas na segurança do sistema e permitindo que terceiros não autorizados realizem compras com cartão de crédito alheio, surge para o banco réu o dever de reparar os prejuízos materiais suportados pela parte autora, ante a ocorrência de defeito na prestação do serviço, na forma como dispõe o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, em situações análogas, já decidiram o Colégio Recursal da Capital e o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, in verbis:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Legitimidade passiva da instituição financeira reconhecida. Cartão de crédito. Débitos não reconhecidos. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Débito inexigível. Imposição da repetição do indébito. Recurso desprovido. A hipótese em tela, então, enseja a inversão do ônus da prova, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, dada a hipossuficiência técnica do consumidor recorrido em face do recorrente. A esse incumbiria demonstrar, destarte, independente da comunicação do autor ou da existência de seguro contra eventos dessa natureza, a regularidade dos débitos supostamente contraídos, comprovando, de forma cabal, que as compras teriam sido realizadas pelo titular do cartão. Isso poderia se dar pela verificação das assinaturas apostas no recibo de compras, por eventuais filmagens do momento das aquisições, e até mesmo por testemunhas que pessoalmente participaram dos eventos. Contudo, o recorrente manteve-se inerte, não produzindo qualquer prova no sentido de comprovar suas alegações.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Cartão de crédito furtado. Compras não realizadas pelo titular do cartão. Existência e validade do consentimento da vítima não demonstrada. Ausência de conferência das assinaturas apostas nos comprovantes de venda, cartão e documento pessoal do titular pelos estabelecimentos conveniados pelo réu. Risco profissional. Inobservância do dever de vigilância e cuidado pela administradora. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Nulidade da cláusula que impõe ao consumidor a responsabilidade pelas compras efetuadas até o momento da comunicação do furto à administradora. Inserção indevida

do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ofensa moral configurada. *Damnum in re ipsa*. Indenização devida. Emprego inadequado da equivalência em salários mínimos. Necessidade de desatrelamento da condenação em salários mínimos para condenação em valor certo e de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial. Redução do arbitramento Recurso provido em parte. (TJSP, apelação cível nº: 0172895- 21.2010.8.26.0000)

DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. Furto. Compras efetuadas por terceiro antes da comunicação do extravio. Falha da prestação do serviço. Responsabilidade objetiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. Fornecimento de produtos e serviços que deve garantir a segurança, inclusive patrimonial, dos usuários. Risco da atividade. Dano moral evidenciado em razão da negativação sofrida pelo Apelado por débito ao qual não deu causa. Todavia, fica reduzido nessa instância para R\$ 20.000,00. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP, Apelação nº 9228459-31.2007.8.26.0000).

Também em igual sentido o entendimento sufragado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, *in verbis*:

CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. 1. A melhor exegese dos artigos 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. No sistema do CDC, fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência. 3. São nulas as cláusulas contratuais que impõem exclusivamente ao consumidor a responsabilidade por compras realizadas com cartão de crédito furtado ou roubado, até o momento da comunicação do furto à administradora. Precedentes. 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (STJ, 3ª Turma, REsp 1.058.221-PR, Reg. 2008/0104709-0, J. 04.10.2011, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU 14.10.2011).

Nessa especial circunstância, à míngua de comprovação na regularidade do débito, que ensejasse os descontos, no importe de R\$ 197,17, debitados mensalmente no benefício previdenciário do autor, a partir de 01.05.2017, e ante o que dispõe o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o réu, independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos danos materiais ocasionados ao autor. Nesse sentido o entendimento jurisprudencial, *in verbis*:

APELAÇÃO. Procedimento Ordinário. Alegação de ocorrência de saques indevidos na conta corrente do demandante. Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos termos dos artigos 3º, § 2º, e 14 do CDC. Ônus da prova que cabe, por isso, ao demandado, consoante previsto no art. 6º, inc. VIII, de referido Código. Requisitos configurados na hipótese vertente. Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo banco. Responsabilidade deste que deve ser reconhecida. Demandante que faz jus à reparação dos danos morais, cuja ocorrência está configurada no presente caso. Astreinte. Admissibilidade. Sentença que merece ser mantida - Recurso improvido, com observação. (TJSP, Apelação nº 0016673-95.2010.8.26.0009).

CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo não reconhecido pela autora, ensejando descontos em sua aposentadoria. Banco que não comprovou a contratação do empréstimo pela autora. Declaração de inexigibilidade do débito mantida. Contudo, restituição simples dos valores indevidamente descontados. Recurso do banco nesta parte parcialmente provido. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Descontos indevidos na parca aposentadoria da autora. Dano moral *in re ipsa* - Recurso do banco nesta parte improvido. DANO MORAL. Quantum indenizatório. Valor da indenização fixado na r. sentença mantida (R\$ 10.000,00). Recurso do banco nesta parte improvido e recurso adesivo da autora improvido. (TJSP; Apelação cível 1002968-52.2016.8.26.0704).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Valor creditado na conta corrente da autora, relativa a contrato de mútuo que a consumidora diz desconhecer - Descontos de parcelas, sem a efetivação do cancelamento do mútuo - Ônus do banco de comprovar a ausência de erro na contratação - Relação que há de ser declarada inexistente, com o retorno das partes ao status quo ante - Dano moral inexistente - Ausência de ofensa a direito da personalidade da autora - Mero aborrecimento não indenizável - Sucumbência recíproca mantida - Autora que, formulando dois pedidos na inicial, viu apenas um ser julgado procedente - Recursos não providos. (TJSP, Apelação Cível 1010968-39.2018.8.26.0003)

Por estes motivos, surge para o Banco-réu o dever de restituir ao autor as respectivas quantias indevidamente debitadas em seu benefício previdenciário, relativamente ao cartão de crédito consignado, vinculado ao contrato bancário número 002394527, incumbindo-lhe, ainda, àquele cessar os respectivos descontos, bem como de se abster de incluir o nome e o CPF do autor nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito.

É importante ressaltar que a devolução dos valores deverá ser simples e não em dobro, na medida em que a situação dos autos não se enquadra na hipótese do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, mormente por não restar comprovada a má-fé do réu, o que se exige para a imposição da repetição de indébito em dobro, conforme predominante entendimento jurisprudencial.

Por outro lado, no que se refere ao dano moral, a correlata indenização não pode ser acolhida.

Na lição abalizada de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

A lesão a bem personalíssimo, contudo, para caracterizar o dano moral, deve revestir-se de gravidade que, segundo Antunes Varella, citado por Sérgio Cavalieri Filho, "há de medir-se por um padrão objetivo e não à luz de fatores subjetivos". Assim, para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o sofrimento, a tristeza, o vexame impingido, devem ser tais que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento e no bem estar psíquicos do indivíduo.

No caso sub judice, não se vislumbra como o fato articulado na inicial - falha na prestação dos serviços bancários - possa ter ocasionado sensações mais duradouras e perniciosas ao psiquismo humano, além do aborrecimento, do transtorno ou do contratempo, característicos da vida moderna e que não configuram o dano moral.

Ademais, o autor não demonstrou, na forma como dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que a ocorrência do fato tenha ocasionado a ele situação que, pela gravidade, pudesse ensejar o dano de natureza não patrimonial, valendo ressaltar que, na situação dos autos, o dano moral não se presume.

Finalmente, considerando que ninguém está obrigado a permanecer jungido a determinado contrato, igualmente deve ser rescindido o negócio jurídico havido com o Banco-réu (contrato de cartão de crédito consignável).

Por essas razões, a pretensão inicial deve ser acolhida parcialmente.

Diante do exposto, rejeito a alegação de prescrição, bem como a preliminar de carência da ação articuladas na contestação anexada a folhas 24/40 e, no mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, rescindindo o contrato de cartão de crédito consignável, vinculado ao contrato bancário sob o número 002394527, declarar inexigíveis quaisquer débitos atinentes ao mencionado contrato, acrescido de eventuais juros e encargos. No mais, condeno o réu, Banco Mercantil do Brasil S.A., na obrigação de fazer consistente em se abster de debitar da conta bancária ou benefício previdenciário do autor, quaisquer valores que tenham origem no aludido contrato, bem como se abstenha de inserir o nome e CPF do autor nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao mencionado negócio jurídico, sob pena de pagamento de multa, a ser arbitrada por este Juízo. Finalmente, condeno o réu a restituir ao autor as respectivas quantias atinentes às parcelas debitadas em seu benefício previdenciário com relação ao aludido contrato

de empréstimo. Os valores deverão ser atualizados monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o desembolso até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ante o que dispõe o artigo 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional.

Deixo de condenar qualquer uma das partes nas custas processuais e nos honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55, da lei 9.099/95.

O valor do preparo, na hipótese de recurso, R\$ 1.500,00 (guia DARE-SP, código 230-6).

Efetuada o pagamento voluntário, mediante depósito judicial, fica, desde já, deferida a expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico em favor do credor, devendo ser indicada a forma pretendida (levantamento ou transferência), o que será certificado no processo após a sua efetivação.

Presentes os requisitos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça.

Defiro a antecipação da tutela, determinando que o réu cesse, imediatamente, os descontos das parcelas mensais debitadas no benefício previdenciário do autor, relativamente ao contrato bancário de número 002394527, bem como se abstenha de incluir o nome e o CPF do autor nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao respectivo negócio jurídico, sob pena de pagar multa diária, no importe de R\$ 300,00, limitada, por ora, a 10 dias.

Oportunamente, proceda-se à baixa, arquivando-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.I.

Diadema, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA